

<제7장 취소소송의 가구제.제2절 가처분>

I. 가처분의 의의

- 가처분이라 함은 민사소송법상 인정되는 가구제 제도로서, 다툼의 대상이 되는 권리 관계에 대하여 현상 변경을 금지하거나 임시적인 지위를 정하여 본안 소송의 판결이 확정될 때까지 권리자의 손해를 방지하는 법원의 잠정적 처분을 말한다. 행정소송은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 특별한 규정이 없는 한 민사소송법의 규정이 준용되므로, 민사집행법상의 가처분 규정이 행정소송에도 적용될 수 있는지가 주요 논의 대상이 된다. 가처분의 목적은 장기간 소요되는 본안 소송으로 인해 권리자가 회복할 수 없는 손해를 입거나, 승소하더라도 실질적인 권리 구제를 받지 못하는 상황을 미리 방지하여 실효성을 확보하는 데 있다. 취소소송에서는 집행정지라는 특유의 가구제 제도가 마련되어 있으나, 그 한계로 인해 가처분 제도의 보충적 역할이 필요하다는 주장이 제기된다.

II. 집행정지의 한계

- 행정소송법상 집행정지 제도는 취소소송의 가구제 수단으로서 중요하지만, 그 본질적인 특성으로 인해 권리 구제에 있어 다음과 같은 한계를 가진다. 이러한 한계가 항고소송에서의 가처분 인정 필요성의 근거가 된다.

1. 소극적인 조치에 한정

- 집행정지는 처분의 효력, 처분의 집행, 절차의 속행을 정지시키는 소극적인 조치에 한정된다. 집행정지는 이미 존재하는 처분의 법률 효과를 일시적으로 잠재우는 것에 그칠 뿐, 행정청에게 특정한 작위 의무를 부과하거나 법률 관계를 적극적으로 변경시키는 것은 불가능하다. 예를 들어 원고에게 특정 자격이나 지위를 임시적으로 부여하는 등의 조치는 집행정지의 범위를 벗어난다.

2. 적극적인 처분에 대해서만 적용

- 집행정지는 적극적인 처분에 대해서만 적용될 수 있다. 행정소송법 제23조 제2항은 처분등의 효력 등을 정지시키는 것을 규정하고 있어, 그 대상이 되는 것은 구체적인 행정처분이다. 따라서 행정청의 거부 처분이나 부작위위법확인소송의 대상인 부작위에 대해서는 정지할 효력이나 집행이 존재하지 않으므로 집행정지를 신청할 수 없다. 거부 처분 취소소송에서 원고가 본안에서 승소하더라도 판결 확정 시까지 행정청의 응답이나 새로운 처분을 강제할 수 없어 발생하는 실질적인 피해는 집행정지로 구제할 수 없다.

3. 공정력 자체가 문제 되지 않는 다툼에서는 미적용

- 집행정지는 행정처분의 공정력과 집행력 유지를 전제로 하는 특례이므로, 공정력 자체가 문제 되지 않는 공법상 계약이나 기타 공법상 법률 관계의 다툼에 대해서는 적용되지 않는다. 이러한 행정소송법상 가구제 수단의 미비는 행정 구제의 공백을 발생시키며, 이를 해소하기 위해 민사집행법상의 가처분 규정을 활용할 필요성이 제기된다.

III. 항고소송에서의 가처분 인정 여부

1. 학설

- 항고소송(취소소송)에서의 가처분 인정 여부에 대하여는 학설이 대립한다.

(1) 부정설

- 부정설은 행정소송법이 집행정지라는 항고소송의 특수성을 반영한 특별 규정을 이미 마련하고 있으므로, 집행정지 이외의 민사 가처분을 보충적으로 적용하는 것은 허용되지 않는다고 주장한다. 특히 가처분이 행정청에 작위 의무를 부과하거나 행정처분의 공정력을 본질적으로 훼손할 위험이 있다는 점을 주요 근거로 든다. 이는 행정의 안정성과 합목적성 유지를 중시하는 입장이다.

(2) 긍정설

- 긍정설은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법이 준용되므로, 집행정지가 포괄하지 못하는 영역(거부 처분이나 부작위 등)에 대해서는 가처분을 보충적으로 적용하여 원고의 실질적인 권리 구제를 도모해야 한다고 주장한다. 특히 소극적 처분 관련 소송의 실효성 확보를 위해 임시의 지위를 정하는 가처분은 필수적이며, 이는 국민의 재판 청구권과 생존권을 보장하는 측면에서 필요하다고 본다.

(3) 절충설

- 절충설은 집행정지의 대상이 되지 않는 영역(거부 처분이나 부작위)에 대해서는 가처분의 적용을 긍정하되, 이미 집행정지 제도가 마련된 적극적 처분에 대해서는 가처분 적용을 부정하는 입장이다. 이는 행정소송법의 규정을 최대한 존중하면서도 권리 구제의 공백을 메우려는 시도이다.

2. 판례

- 판례는 일관되게 항고소송에서의 가처분 적용을 부정하는 입장이다. 대법원은 행정소송법이 집행 정지에 관하여 행정처분의 공정력과 행정의 안정성을 고려한 특별 규정인 집행정지 제도를 마련하고 있으므로, 행정처분의 효력이나 집행 정지를 구하는 소송에서는 민사집행법상의 가처분 규정을 준용할 수 없다고 판시하고 있다. 즉, 집행정지 규정을 민사 가처분 규정의 특별 규정으로 보아 그 적용을 배제하는 것이다. 다만, 판례는 최근 거부 처분 취소소송의 경우 실효성 확보를 위한 가처분의 필요성은 인식하고 있으나, 현행법의 해석론으로는 인정을 유보하는 태도를 유지하고 있다.

3. 검토

- 항고소송에서의 가처분 인정 여부는 행정소송의 실효성 확보라는 권리 구제 측면과 행정의 법적 안정성 유지라는 공익적 측면이 충돌하는 지점이다. 현행 행정소송법의 명문 규정은 집행정지 외의 가처분을 인정하고 있지 않으며, 이미 처분 취소를 전제로 하는 집행정지 제도가 마련되어 있다는 점에서 판례의 부정설은 해석론상 타당성을 가진다. 그러나 거부 처분 취소소송과 같이 집행정지로 구제될 수 없는 영역에 대해서는 원고가 장기간 권리 구제를 받지 못하여 심각한 피해를 입을 수 있으므로, 입법적인 개선이 절실하다. 해석론적으로는 집행정지의 대상이 될 수 없는 소극적 처분등에 한정하여 임시 지위를 정하는 가처분을 보충적으로 인정하는 절충설이 권리 구제에 보다 적합하다고 판단된다.

IV. 당사자소송에서의 가처분

- 당사자소송이라 함은 행정청의 처분등을 직접 다투는 것이 아니라, 공법상의 법률 관계에 대하여 그 한 쪽 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송을 말한다. 당사자소송은 공법적 법률 관계를 다투는 점에서 항고소송과 유사하지만, 처분의 효력을 다투는 것이 아니며, 법률 관계의 다툼이라는 점에서 민사소송과도 유사한 성격을 지닌다. 행정소송법은 당사자소송에 대하여 집행정지 제도를 별도로 규정하고 있지 않다. 이는 집행정지 제도가 공정력을 가진 행정처분을 전제로 한다는 특수성에 기인한다. 따라서 당사자소송의 가구제 수단에 대하여는 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사집행법상의 가처분 규정이 제한 없이 준용된다. 즉, 당사자소송에서는 원고가 본안 청구권의 존재와 보전의 필요성을 소명하면, 법원은 임시의 지위를 정하는 가처분 또는 다툼의 대상에 관한 가처분 등을 허용할 수 있다. 예를 들어 공무원 지위 확인 소송에서의 임시 지위 가처분이나, 공법상 금전 지급을 구하는 소송에서의 다툼의 대상에 대한 가처분 등이 이에 해당한다.

V. 결론

- 항고소송에서의 가처분 인정 여부는 학설의 대립에도 불구하고 판례는 집행정지 규정을 특별 규정으로 보아 가처분 적용을 부정하고 있다. 반면, 당사자소송은 처분의 공정력이 문제 되지 않아 집행정지 제도가 적용될 수 없으므로, 민사집행법상의 가처분 규정이 준용되어 폭넓게 인정된다. 행정소송의 실효성 제고 및 국민의 권리 구제를 위해 행정소송법의 가구제 영역에 대한 입법적 보완, 특히 항고소송에서의 보충적 가처분 인정의 필요성이 매우 크다고 할 수 있다.